

1505488-85.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... caso, se verifica entre o bloco de delitos de roubo qualificado, e não entre os crimes integrantes do nexo de continuidade, que dizem respeito apenas ao roubo simples. Ou seja: a ficção do crime continuado se observou entre os delitos de roubo simples (art. 157 do CP) e o" bloco de crimes "de roubos qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1505488-85.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505488-85.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061391/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 23397670 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 2061391 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO PATRIK LA PASTINA BALBINO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

PABLO PATRIK LA PASTINA BALBINO e BRUNO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 157, §2º, inciso II (vítima Neuri); no artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, em concurso formal (vítimas Fabiana e Fabio); e no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. Artigo 14, inciso II (vítima Alexandre), todos c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque em 28 de fevereiro de 2022, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), na Rua Ipiranga, nesta Capital, , qualificado à fl. 13, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular, um relógio e uma aliança pertencentes a Neuri Luiz Rubetti Junior.

Consta, ainda, que no dia 04 de março de 2022, por volta das 14h25min, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), na Rua Palacete das Águias, Campo Belo, nesta Capital, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, eles subtraíram, para si, mediante grave ameaça, os aparelhos celulares e as alianças pertencentes a Fabiana Rayser de Souza e Silva e Fabio Rogério Verzbiskas.

Por fim, consta, que no dia 05 de março de 2022, por volta das 10h40min, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), na Rua Palacete das Águias, nº 10, Campo Belo, nesta Capital, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, tentaram subtrair, para si, mediante grave ameaça, bens pertencentes a Alexandre Nose Júnior, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Os réus foram presos em flagrante por ocasião dos fatos praticados no dia 05/03/2022.

Realizada a audiência de custódia, as prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas, fls. 72/74

Oferecida a denuncia, foi ela recebida, fls. 107/108, e os réus citados pessoalmente, fls. 126/128.

Pablo ofereceu sua resposta a acusação através de Defensora Publica, fls. 132/133 e Bruno através de defensora constituída, fls. 144/145.

Não sendo o caso de absolvição sumária, designei audiência de Instrução, Debates e Julgamento para o dia 02/08/2022.

Na data de hoje, as quatro vítimas foram ouvidas assim como dois policiais militares. Os réus foram interrogados ao final.

Ultrapassada a fase do artigo 402 do CPP, as partes se manifestaram em alegações orais. O Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denuncia. As Defesas pleitearam a absolvição de ambos. Subsidiariamente, pugnaram pela fixação da pena mínima, reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão (PABLO), regime aberto ou semiaberto, continuidade delitiva entre os delitos e possibilidade de recurso em liberdade.

Encontram-se ainda nos autos o auto de prisão em flagrante, fls. 6/7, auto de exibição e apreensão, fls. 16, Boletim de ocorrência alusivo aos fatos ocorridos em 05/03/2022, fls. 35/39, e relatório final da Autoridade Policial, fls, 48/51.

É o relatório.

Decido.

É procedente a ação penal nos exatos termos da denuncia porque, ao final da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria dos delitos por parte dos acusados, vejamos.

A materialidade veio bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, fls. 6/7, auto de apreensão e exibição das duas bicicletas apreendidas em poder dos acusados, fls. 16 e boletim de ocorrência alusivo aos fatos bem como o relatório final da Autoridade Policial, fls, 48/51.

A autoria, de igual forma, restou comprovada extreme de dúvidas.

No dia de hoje os réus foram submetidos a reconhecimento.

Deixo consignado que o corréu PABLO, que se encontrava nas dependências do CDP de Pinheiros, ostentou a placa de numero 2.

O corréu BRUNO, presente no Fórum, ostentou a placa de numero 4.

No dia designado para a realização da audiência de instrução, debates e julgamento, as 4 vítimas foram ouvidas. Passo a transcrever suas oitivas.

A vítima Neuri não tem certeza mas acredita que seja o numero 2 (Pablo) na sala de reconhecimento do forum reconheceu o de numero 4 (Bruno). No dia dos fatos, deixou o seu carro ao lado da empresa que trabalha para lavar. Depois que pegou o carro, parou para comprar uns produtos que estavam sendo vendidos por um rapaz em uma van. Foi abordado por três individuos e um deles já pegou o celular. Exigiram a aliança e seus demais objetos. A principio opôs certa resistência mas ai, o terceiro, além de simular estar armado pegou uma garrafa de vidro e veio em sua direção para agredi-lo. Imediatamente entregou seus pertences. Levaram seu celular, relógio e

sua aliança. Os três estavam de bicicleta. O numero 4 foi o que sugeriu estar armado. O numero 2 foi o que o abordou diretamente. Na delegacia compareceu 2 vezes a primeira vez para fazer o BO e a segunda foi chamado para fazer reconhecimento. Durante o reconhecimento estavam apenas os dois indivíduos presos. Os bens não foram localizados. Eles tentaram mas não conseguiram fazer qualquer negociação com bancos, através dos aplicativos existentes em seu celular. O prejuízo ficou em R\$ 12.000,00. Três vítimas estavam na delegacia mas o reconhecimento foi individualizado. Recebeu uma ligação da policia sobre a prisão de dois indivíduos em flagrantes e que estavam praticando roubos na região de bicicleta. A vítima Fábio não conseguiu reconhecer nenhum deles. Era por volta das 13 horas quando foi assaltado. Estava indo com a esposa ao mercado. Duas pessoas vieram de bicicleta. Um veio na frente do depoente e outro foi para frente da esposa. Demorou um pouco para perceber que era um assalto e achou que poderia pedir ajuda porque a avenida era bem movimentada. Foi ameaçado de levar um tiro. Começaram a tirar as alianças e os relógios. Não levaram o celular. Ligou para a policia militar e cinco minutos depois ela chegou. Fez BO on line. No dia seguinte fez o reconhecimento dos dois na delegacia e não teve duvidas. Era muito recente. Os bens não foram localizados. Os relógios tinham rastreador mas preferiu desligar. Fez o reconhecimento e depois a esposa também fez. Estava sozinho na sala de reconhecimento e fez sozinho. Estavam apenas duas pessoas na sala de reconhecimento. Quando chegou as outras vítimas já tinham ido embora. Pelo que soube as vítimas já tinham ido embora. Pelo que sabe a esposa também os reconheceu. A câmera de segurança de um prédio próximo flagrou os acusados instantes antes do assalto, há 30 ou 40 metros de onde foram abordados, e através dessas imagens reconheceu os acusados com toda a certeza. E essas pessoas que viu nessas imagens foram as mesmas pessoas que reconheceu na delegacia. Não viu armas com eles. Fabiana, também vítima e esposa de Fábio, reconheceu o número 2 (PABLO) e o numero 4 (BRUNO). No dia estava indo com o marido ao mercado. Até entenderem que estavam sendo assaltados demorou uns 10 segundos. Pediram relógio e aliança. Os dois estavam de bicicleta. Depois que abordaram ele lembra-se que um deles teria dito ao marido que ia atirar. Entendeu que era um assalto. Em momento algum encostaram as mãos no casal. Fizeram BO on line. Dois dias depois foram chamados para reconhecimento. Na delegacia os reconheceu. Não teve duvidas. Os reconheceu depois do marido. Somente os dois foram colocados para serem reconhecidos. Cinco minutos depois do roubo, chamou a policia e cinco minutos depois eles levantaram imagens do que aconteceu. Acha que as outras vítimas também os reconheceram. Tinham mais duas vítimas. Foi a ultima a reconhecer. Uma das vítimas disse que o reconhecimento foi positivo. As vítimas foram ouvidas separadamente e isso tem certeza. Alexandre reconheceu o numero 4 (BRUNO) e não conseguiu reconhecer PABLO. Mora em um sobrado no Jabaquara e resolveu limpar a calçada. Saiu pelo portão social e nisso, dois elementos de bicicleta chegaram e um deles o cercou e o outro ficou na bicicleta. Um deles falou grosso "me dá o anel, me dá o anel" nisso eles vacilaram e conseguiu correr para dentro de casa. Depois de alguns minutos, saiu e viu que eles fugiram pela rua atrás. Nisso uma viatura da Força Tática apareceu e ele a chamou. Os policiais saíram e voltaram cerca de 10 minutos depois. Depois de uma hora encontrou os policiais na feira e pediram para que a vítima fosse a delegacia. Lá conseguiu fazer o reconhecimento dos dois. As bicicletas também foram apreendidas mas não teve condições de reconhece-las. Fez o reconhecimento em uma salinha junto com o delegado. Pode afirmar que o numero 4 de hoje foi um dos que reconheceu na delegacia. Na delegacia estava o declarante, a outra vítima que acabou de sair (Neuri) e a sua esposa e uma outra mulher loira que não sabe se foi vítima dessas pessoas. Não houve perda financeira. Após questionamentos advindos da defesa de BRUNO quanto ao reconhecimento, esta magistrada percebeu que a vítima apresentou duvida e então determinei o refazimento do reconhecimento nos exatos moldes feitos anteriormente. Refeito o reconhecimento, a vítima voltou atrás. Não foi capaz de reconhecer o numero 4. Na delegacia conseguiu reconhecer pelo rosto. Em solo policial, só duas pessoas estavam para ser reconhecidas. Pois bem.

Quanto aos reconhecimentos algumas observações se fazem necessárias.

Com efeito, não é possível exigir-se das vítimas, pessoas que passaram por uma situação de violência e estresse, causadora de muito nervosismo e medo, que elas guardem a fisionomia de seus agressores de forma que possibilite o reconhecimento. Algumas vezes, as vítimas de roubos e outras agressões conseguem se recordar com facilidade, do rosto e das características físicas dos agentes. Outras vezes não conseguem se lembrar de nada.

Além do estresse causado no psicológico das vítimas, o fator tempo também é uma importante causa a ser considerada.

E quando falo em "tempo", não me refiro apenas ao tempo decorrido entre o fato e o reconhecimento mas também ao tempo que durou a agressão.

Existe ainda aquelas situações em que os agressores não permitem que a vítima olhe para eles bem como situações em que eles se encontram de máscara (COVID), capacete, capuz, óculos escuros.

Por fim, existem as situações em que a vítima não pode reconhecer o agressor na medida que veio a óbito.

Portanto, se o reconhecimento da vítima fosse absolutamente necessário para se chegar a conclusão homicídios e latrocínios consumados seriam insolúveis e seus autores seriam eternamente brindados com a impunidade.

Evidentemente que essa ideia é absurda.

Daí porque, uma sentença penal condenatória deve se basear em elementos informativos constantes no inquérito policial bem como nas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, cuja análise racional a ser feita pelo Magistrado o conduz a conclusão lógica da autoria e da materialidade do delito em julgamento.

E, no caso concreto, a prisão em flagrante dos acusados bem como a apreensão das duas bicicletas aliadas aos reconhecimentos feitos na delegacia, a meu ver extrema de dúvidas, aliados as declarações das vítimas prestadas em juízo no dia de hoje assim como as declarações dos policiais autorizam o edito condenatório nos termos da denúncia.

Com efeito, a vítima Neuri reconheceu os dois acusados no dia de hoje.

Fabio, não conseguiu reconhece-los. Contudo, sua esposa Fabiana, que estava junto com o marido por ocasião do roubo e que também teve seus pertences levados pelos acusados, os reconheceu em juízo sem titubear. Os dois estavam, cada qual, a bordo de uma bicicleta.

Alexandre, vítima do roubo tentado pelo qual os réus foram presos em flagrante, em um primeiro momento reconheceu Bruno (4) mas depois, diante de uma indagação da advogada de defesa, voltou atrás e disse que não tinha condições de reconhecer ninguém.

Contudo, na delegacia, Alexandre foi muito objetivo ao descrever as vestes dos acusados. Um estava de camisa listrada e o outro de camisa cinza. As fotografias de fls. 43 e 45 não deixam dúvidas.

As quatro vítimas declararam que foram atacadas por indivíduos de bicicleta. Neuri afirmou que foi atacado por três assaltantes. Fabio, Fabiane e Alexandre declararam que o ataque foi perpetrado por dois indivíduos. Em comum, todos de bicicleta.

Em todas as situações exigiram os anéis (alianças) das vítimas.

Em todas as oportunidades agiram em concurso de agentes.

E as versões apresentadas pelas vítimas são merecedoras de toda credibilidade, uma vez que em regra são pessoas isentas e que não teriam interesse algum em prejudicar injusta e gratuitamente indivíduos inocentes, que sequer conheciam.

Tanto é verdade que em juízo foram extremamente cautelosas por ocasião dos reconhecimentos.

Aliás, ao contrário do que foi mencionado pela Douta Defensora Pública, fls. 185, Pablo e Bruno foram presos em flagrante por tentativa de roubo bem como as vítimas Neuri e Fabiane reconheceram os dois em juízo, sem qualquer dificuldade.

E os reconhecimentos feitos na delegacia de polícia, ainda que de forma irregular porque não obedeceram o que determina o artigo 226 do Código de Processo Penal quanto a colocação de outras pessoas na condição de figurantes, de forma alguma acarreta nulidade do ato. E mais. Somente a vítima Alexandre declarou que o reconhecimento foi feito em conjunto, fato negado veementemente pelas outras três

vítimas que estavam bem mais firmes e seguras e que asseguraram que o reconhecimento em sede policial foi feito de forma individual. Nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o de roubo, as declarações da vítima, quando firmes e harmônicas, têm relevante valor probatório. Se de um lado o acusado tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro o ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Confira-se:

[...] “Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima como espécie inculpada no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosas, o que se harmoniza ao caso em apreço”. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/04/2019).

Mas não é só.

Os policiais militares também foram ouvidos e confirmaram os motivos que os levaram a prender Pablo e Bruno em flagrante. Além do que, reconheceram os dois réus como sendo as pessoas que prenderam por ocasião da notícia da tentativa de roubo da vítima Alexandre, vejamos.

Tenente Hélio reconheceu os dois réus. Recebeu informação via COPOM de que duas pessoas haviam praticado uma tentativa de roubo e que um deles estava com uma camisa de time de futebol. Os dois estavam, cada um, em uma bicicleta. Cinco minutos depois os visualizou. Efetuaram a abordagem e com eles nada foi encontrado de ilícito mas eles acabaram confessando a tentativa de roubo. Uma equipe foi até onde a vítima se encontrava e colheu mais informações. A vítima disse que eles tentaram roubar o celular. Não se recorda o nome dessa vítima. A vítima da tentativa de roubo, pelo que sabe, os reconheceu na delegacia. Eles estavam próximos a uma feira. As características deles eram exatamente as que haviam sido mencionado pela vítima. Tinham imagens que circulavam em grupos de whatsapp de policiais as quais coincidiam com as características dos acusados. Eles confessaram a tentativa de roubo e outros roubos praticados na região. Eles foram informados sobre seus direitos.

O policial Jonatas também reconheceu os acusados de uma tentativa de roubo em março. A vítima ligou 190 e afirmou que ambos estavam de bicicletas. Cerca de 5 minutos depois os localizaram. Nada de ilícito foi localizado com eles. Na delegacia a vítima reconheceu os acusados, fato que soube depois. Eles admitiram que haviam tentado roubar. Eles tentaram roubar um celular e uma aliança, a vítima saiu correndo, algo do tipo. Tinham algumas imagens de roubos que estavam com os policiais. Não se recorda de tê-los reconhecido nessas imagens mas pode afirmar que eram sempre as mesmas pessoas que apareciam nessas imagens praticando roubos de bicicleta. Parou os dois em razão das características repassadas pela vítima. Eles confessaram a tentativa bem como que estavam efetuando outros roubos na região. E não existe demonstração probatória de qualquer interesse desses policiais militares em prejudicar pessoas inocentes, não havendo daí motivo para que essa prova seja desprezada.

Aliás, como qualquer outra testemunha, os policiais prestaram compromisso de dizer a verdade e não viriam a Juízo para apresentar versão mendaz, apenas para justificar a diligência que realizaram.

Não se pode, pois, desconsiderar a prova em questão por mera presunção, sem demonstração de suspeita ou má-fé, ou prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos.

Nesse sentido: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

Ainda: "Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas." (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Interrogados em juízo, os réus Pablo e Bruno optaram pelo silêncio.

Assim, não deram suas versões dos fatos motivo pelo qual somente as versões das vítimas e dos policiais serão consideradas.

Portanto, não há espaço algum para dúvidas quanto a procedência da denúncia.

Pois bem.

Superada a questão quanto a autoria e materialidade dos delitos, passo a tratar de alguns pontos referentes a dosimetria da pena.

Penso que no caso dos autos, os acusados praticaram 4 roubos qualificados pelo concurso de agentes.

Em relação a dois deles, mais especificamente os que foram praticados contra Fabio e Fabiane, de rigor o reconhecimento do concurso formal de crimes. Ambos estavam juntos e foram roubados mediante uma só ação dos agentes.

E, esse roubo único, praticado nos termos do artigo 70 do Código Penal, bem como os outros dois, praticados contra Neuri e Alexandre, foram praticados em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, caput, segunda figura, do Código Penal.

Após melhor analisar a questão atinente a dosimetria da pena nos casos em que se verifica a incidência do concurso material e continuidade delitiva, alterei entendimento anterior e passei a decidir nos termos que esta a questão vem sendo abordada pelo Superior Tribunal de Justiça que não admite a incidência dos dois aumentos, no caso pelo concurso formal e pela continuidade delitiva, sob pena da prática do bis in idem, situação inadmissível no Direito Penal.

A decisão que abaixo transcrevo bem elucida a questão, vejamos:

"O agravante pretende a aplicação da regra do concurso formal para o bloco de crimes de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e, após essa operação, a aplicação da regra da continuidade delitiva entre estes delitos e o de roubo simples, também praticado pelo recorrido, pontuando não ser essa a situação em que a jurisprudência dos Tribunais Superiores rejeitam a concomitância das figuras, nesses termos: "[...] a regra do concurso ideal, no presente caso, se verifica entre o bloco de delitos de roubo qualificado, e não entre os crimes integrantes do nexo de continuidade, que dizem respeito apenas ao roubo simples. Ou seja: a ficção do crime continuado se observou entre os delitos de roubo simples (art. 157 do CP) e o" bloco de crimes "de roubos qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do CP), enquanto que o concurso formal se verificou apenas dentro deste bloco delitivo. Desse modo não é, absolutamente, a situação em que a jurisprudência do STF e do STJ rejeitam a concomitância das duas figuras, pois o crime que permitiu a caracterização do concurso formal não integrou o nexo de continuidade." (fl. 448)

Assim decidiu a Corte de origem: "O Superior Tribunal de Justiça, entretanto, firmou o entendimento de que" «a hipótese em que restar caracterizada a ocorrência das figuras do concurso formal e do crime continuado, a fim de evitar o bis in idem, é de rigor fazer incidir, na terceira fase da dosimetria, tão somente a exasperação de pena atinente à continuidade delitiva "(STJ, HC 470.750/SP).

Assim, considerando que os 3 (três) roubos qualificados foram praticados em concurso formal e em continuidade delitiva com o roubo simples, exaspero a pena no patamar intermediário de 1/4 (um quarto), sobre a pena mais grave (7 anos de reclusão), tomando-a definitiva em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 27 dias-multa." (fl. 367) In casu, observa-se que restou firmada no acórdão profligado a continuidade delitiva entre os quatro crimes de roubo. Assim, entendeu a Corte de origem caracterizada a continuidade delitiva entre os delitos, razão pela qual aplicou a jurisprudência desta Egrégia Corte de

que, havendo concurso formal e continuidade delitiva, aplica-se a regra da continuidade delitiva a toda a série de crimes, afastando-se o concurso formal. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. CUMULAÇÃO DE AUMENTOS PELA CONTINUIDADE DELITIVA E PELO CONCURSO FORMAL. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese de ocorrência de concurso formal e continuidade delitiva, afasta-se o primeiro e aplica-se apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 610.352/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2021) Se o parquet entende ser caso de se fazer o distinguish, deveria fazê-lo, e não simplesmente pedir o retorno do que restou decidido no primeiro grau, pois, da forma em que se deu a empreitada criminosa, a única maneira de se negar a aplicação da jurisprudência desta Corte seria impugnar a ocorrência de continuidade delitiva, porque, na concomitância entre os dois institutos - concurso formal e continuidade delitiva, prevalece a última. Assim, incide o óbice da Súmula n. 83/STJ. Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para conhecer do agravo em recurso especial e, nos termos da Súmula n. 568/STJ, negar provimento ao recurso especial. Publi que-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2022. JOEL ILAN PACIORNIK Relator (STJ - AgRg no AREsp: 1952262 GO 2021/0263100-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 15/03/2022) (grifei)

Portanto, ainda que reconheça a incidência do concurso formal, o aumento a ser aplicado será apenas o atinente ao crime continuado.

Assim sendo, demonstrada a procedência da imputação contra os réus, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. , Dosimetria da pena

Como a situação pessoal dos réus é idêntica, passo a dosar a pena conjuntamente para ambos.

1) Vítima NEURI:

Considerando as circunstâncias judiciais, favoráveis a ambos, fixo a pena em seu mínimo na medida em que os acusados são primários e ostentam bons antecedentes, fls. 96/97 e 101. Não vislumbro outros motivos para que a pena seja fixada além de seu mínimo já que a violência empregada não desborda da grave ameaça inserida no tipo penal e os prejuízos causados não foram de grande monta. Assim, nesta fase, a pena resta fixada em 04 (quatro) de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa

Em segunda fase, ressalta-se a não aplicação da agravante relacionada pelo Ministério Público prevista no art. 61,II, j, do Código Penal, dado que tal circunstância (calamidade pública) não guarda nexo causal com o caso, sendo que os réus não se aproveitaram da situação de pandemia causada pelo COVID-19 para o cometimento do delito. Adota-se, pois, interpretação restritiva acerca da aplicação dessa agravante, sob pena de aplicá-la a todo e qualquer delito cometido em território nacional a partir de 16.03.2020. Observo que Bruno é menor imputável. Contudo, a pena já foi fixada em seu mínimo motivo pelo qual não poderá ser diminuída ainda mais.

Em terceira fase, reconheço a qualificadora do concurso de agentes e aumento a pena em 1/3 (um terço). Chego a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa

2) vítima FABIO:

Considerando as circunstâncias judiciais, favoráveis a ambos, fixo a pena em seu mínimo na medida em que os acusados são primários e ostentam bons antecedentes, fls. 96/97 e 101. Não vislumbro outros motivos para que a pena seja fixada além de seu mínimo já que a violência empregada não desborda da grave ameaça inserida no tipo penal e os prejuízos causados não foram de grande monta. Assim, nesta fase, a pena resta fixada em 04 (quatro) de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa

Em segunda fase, ressalta-se a não aplicação da agravante relacionada pelo Ministério Público prevista no art. 61,II, j, do Código Penal, dado que tal

circunstância (calamidade pública) não guarda nexos causal com o caso, sendo que os réus não se aproveitaram da situação de pandemia causada pelo COVID-19 para o cometimento do delito. Adota-se, pois, interpretação restritiva acerca da aplicação dessa agravante, sob pena de aplicá-la a todo e qualquer delito cometido em território nacional a partir de 16.03.2020. Observo que Bruno é menor imputável. Contudo, a pena já foi fixada em seu mínimo motivo pelo qual não poderá ser diminuída ainda mais.

Em terceira fase, reconheço a qualificadora do concurso de agentes e aumento a pena em 1/3 (um terço). Chego a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa

3) vítima FABIANA:

Considerando as circunstâncias judiciais, favoráveis a ambos, fixo a pena em seu mínimo na medida em que os acusados são primários e ostentam bons antecedentes, fls. 96/97 e 101. Não vislumbro outros motivos para que a pena seja fixada além de seu mínimo já que a violência empregada não desborda da grave ameaça inserida no tipo penal e os prejuízos causados não foram de grande monta. Assim, nesta fase, a pena resta fixada em 04 (quatro) de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Em segunda fase, ressalta-se a não aplicação da agravante relacionada pelo Ministério Público prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, dado que tal circunstância (calamidade pública) não guarda nexos causal com o caso, sendo que os réus não se aproveitaram da situação de pandemia causada pelo COVID-19 para o cometimento do delito. Adota-se, pois, interpretação restritiva acerca da aplicação dessa agravante, sob pena de aplicá-la a todo e qualquer delito cometido em território nacional a partir de 16.03.2020. Observo que Bruno é menor imputável. Contudo, a pena já foi fixada em seu mínimo motivo pelo qual não poderá ser diminuída ainda mais.

Em terceira fase, reconheço a qualificadora do concurso de agentes e aumento a pena em 1/3 (um terço). Chego a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa

4) vítima ALEXANDRE

Considerando as circunstâncias judiciais, favoráveis a ambos, fixo a pena em seu mínimo na medida em que os acusados são primários e ostentam bons antecedentes, fls. 96/97 e 101. Não vislumbro outros motivos para que a pena seja fixada além de seu mínimo já que a violência empregada não desborda da grave ameaça inserida no tipo penal e os prejuízos causados não foram de grande monta. Assim, nesta fase, a pena resta fixada em 04 (quatro) de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Em segunda fase, ressalta-se a não aplicação da agravante relacionada pelo Ministério Público prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, dado que tal circunstância (calamidade pública) não guarda nexos causal com o caso, sendo que os réus não se aproveitaram da situação de pandemia causada pelo COVID-19 para o cometimento do delito. Adota-se, pois, interpretação restritiva acerca da aplicação dessa agravante, sob pena de aplicá-la a todo e qualquer delito cometido em território nacional a partir de 16.03.2020. Observo que Bruno é menor imputável. Contudo, a pena já foi fixada em seu mínimo motivo pelo qual não poderá ser diminuída ainda mais.

Em terceira fase, reconheço a qualificadora do concurso de agentes e aumento a pena em 1/3 (um terço). Chego a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Tentado, diminuo em 1/3 (um terço) em razão do iter criminis. Com efeito, embora os acusados tenham iniciado a execução do crime de roubo, a vítima correu para o interior de sua residência e eles saíram em fuga. A consumação do crime, a meu ver, restou longe de ser concluída. Assim, diminuída a pena em sua carga redutora máxima, chego a 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa.

Artigo 71, § único do Código Penal.

Os roubos praticados contra as três primeiras vítimas e as vítimas M.P.S.R. e T.C.R foram continuados nos exatos termos do artigo 71 do CP. Com efeito, o acusado praticou 4 delitos de roubo qualificado, o dois deles em concurso formal e em relação aos dois ultimos em continuidade delitiva qualificada. Contudo, como já afirmado anteriormente, afastei a incidência do concurso formal porque a única causa de aumento a ser aplicada é a referente a continuidade delitiva. No caso de continuidade delitiva especifica, descrita no artigo 71, segunda figura, do Código Penal, além dos requisitos exigidos para aplicação do benefício penal da continuidade delitiva simples, exige-se que os crimes praticados: a) sejam dolosos; b) realizados contra vítimas diferentes; e c) cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

A lei penal somente estipula a exasperação máxima da continuidade delitiva especifica (até o triplo), não apontando a fração mínima aplicável.

Contudo, já decidiu o STJ:

"Em sintonia com o caput do artigo 71 do Código Penal, impõe-se a utilização do parâmetro mínimo de 1/6, sob pena da continuidade delitiva especifica tornar-se inútil, por ser substituída pelo concurso material, cujo critério do cúmulo material é o teto da exasperação da continuidade. 6. Estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva especifica, descrita no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. 7. Reconhecida a prática de dois delitos de roubo e a valoração negativa dos antecedentes do réu, mostra-se plenamente proporcional o aumento da pena na fração de 2/3, inexistindo, pois, o alegado constrangimento ilegal sustentado pela defesa, pois, tratando-se de crime continuado específico, não se utiliza apenas o critério objetivo da quantidade de crimes, devendo o julgador sopesar, também, as circunstâncias judiciais do acusado, que são bastante desfavoráveis. 8. Writ não conhecido. (HC n. 398.409/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/12/2017)

Daí porque, considerando que foram 4 roubos praticados a pena maior deve ser aumentada de 1/4 (um quarto)). A pena a ser considerada como base de cálculo para o fim do aumento pela continuidade é a do roubo consumado, no caso, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa que, aumentada de 1/4 (um quarto) atinge o resultado final de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão 14 dias multa.

Tendo em vista a natureza do roubo, praticado com grave ameaça à pessoa, exercida pelo concurso de agentes e utilização de arma de fogo, o que revela periculosidade de seus executores, e, ainda, pelo montante da pena aplicada, para garantia da ordem pública os acusados não poderão recorrer em liberdade, deverão ser recomendados na prisão em que se encontram e iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME FECHADO (art. 33, parágrafos 2º "a" e 3º, do Código Penal).

E de regime mais brando não há que se falar, nos termos da r. decisão proferida pelo i. Desembargador Luiz Soares de Mello, colacionada em apelação Criminal nº 1.439-961-1, da E. 6ª Câmara do tribunal de Alçada Criminal, relator Maia da Cunha: "Não é mais possível ignorar os traumatismos das grandes e pequenas cidades, do país inteiro, enfim, com a onda nefasta de violência que assola nossa terra. Não é mais possível compactuar com benesses indevidas, "data vênica", com moderações impossibilitadas a quem não é e nem pretende assim ser e nem foi, no caso com a sociedade onde vive e com os milhares de cidadãos honrados deste país, que lutam e sofrem para sobreviver. Não é mais possível fechar os olhos para o fato de que regime nenhum, senão o fechado, é que extirpa do convívio gente que não faz por merecer este. Não é mais possível a qualquer, muito menos ao Judiciário, negar realidade evidente, encarada e pendente, que é a quase falência de sistemas alternativos de cumprimento de pena. Ou se encarcera o cidadão que merece ser

encarcerado, tais aqueles que, como aqui, praticam violência e esquecem-se de que vivem em coletividade, ou se joga por terra um dos atributos mais marcantes do Judiciário, que também e obviamente é o de combater a criminalidade. Que se faça até onde as mãos alcançam. E se o Judiciário pode fazê-lo, que o faça, desde logo e de pronto, para que não seja posteriormente responsabilizados.” (Revisão Criminal nº 461.926/2, São Paulo, VT9807).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra:

1)BRUNO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA, RG: 37799409, e o CONDENO como incurso no artigo o artigo 157, §2º, inciso II (vítimas Neuri, Fabiana e Fabio) e no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. Artigo 14, inciso II (vítima Alexandre), nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal, a pena total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime fechado e 14 dias multa, piso mínimo.

2)PABLO PATRIK LA PASTINA BALBINO, RG: 50239477, e o CONDENO como incurso no artigo o artigo 157, §2º, inciso II (vítimas Neuri, Fabiana e Fabio) e no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. Artigo 14, inciso II (vítima Alexandre), nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal, a pena total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime fechado e 14 dias multa, piso mínimo.

Tendo em vista a natureza dos roubos, praticado com grave ameaça à pessoa, exercida pelo concurso de agentes o que revela periculosidade de seus executores, em cumprimento ao que prescreve o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reviso a necessidade da manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do acusado.

Com efeito, os acusados foram denunciados e condenados pela pratica de crime gravissimo, e que vêm causando grande instabilidade social, motivo pelo qual deve ser severamente reprimido. Facilmente a situação poderia ter caracterizado um crime de latrocínio.

A gravidade do crime é concreta assim como é concreta a necessidade da manutenção dos acusados no cárcere pois a medida extrema encontra esteio também na efetiva aplicação da lei penal e na manutenção da ordem pública, que precisa ser preservada.

“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face de gravidade do crime e de sua repercussão.” (Supremo Tribunal Federal, Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033).

Acrescente-se, ainda, que a primariedade e a ausência de maus antecedentes não são elementos que, por si só, impedem a decretação da prisão preventiva, quando outros se fazem presentes e recomendam a medida extrema.

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“a primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos para a decretação da prisão preventiva: as causas enumeradas no artigo 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos”. (in Código de Processo Penal Comentado, 8ª edição, Ed. RT, p. 627, 2008, São Paulo).

Naturalmente que não têm condições de responder ao processo em liberdade.

Assim, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal nego o recurso em liberdade, bem como mantenho a PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor dos acusados e determino sejam eles recomendados na prisão em que se encontram. A fixação de outras cautelares, neste caso concreto, não se mostram suficientes. Após o trânsito em julgado, mantida esta, nome do réu no rol dos culpados, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Por fim, oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

São Paulo, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA